

1501991-30.2021.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229619/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA,

19806616 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1098/21/100 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2229619 -

DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

1ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501991-30.2021.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501991-30.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229619/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA,

19806616 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1098/21/100 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2229619 -

DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAQUIM CARLOS FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra JOAQUIM CARLOS FERNANDES, vulgo "Baiano", qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06. Consta na denúncia que no dia 23/08/2021, por volta das 21h20min, na rua Décio Gava, próximo da AFUPE (Associação dos Servidores Penitenciários), nesta cidade e Comarca de Andradina, transportava, para fins de tráfico, 01 (um) "tijolo" de "maconha", com peso aproximado de 408,72 g, substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A exordial acusatória narrou que: "Segundo se apurou, no dia dos fatos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela cidade, quando verificaram que o denunciado, conhecido pela prática de tráfico de drogas, apresentou comportamento suspeito ao notar a viatura policial. Nesse contexto, o denunciado empreendeu fuga com seu veículo, mas foi interceptado pelos militares, próximo ao clube dos agentes penitenciários. Em revista veicular, os militares localizaram um "tijolo" de "maconha", com peso aproximado de 408,72g, debaixo do banco do condutor. Além do entorpecente, os agentes estatais encontraram uma faca e a quantia de R\$ 1.758,00 em notas diversas".

A denúncia foi recebida em 23.08.2021 (fls. 128/130), sendo também determinada a citação.

O acusado, regularmente citado (fls. 145), ofertou defesa preliminar (fls. 171/185).

Após análise da peça defensiva, afastada possibilidade de absolvição sumária (fls. 202/203).

Sendo designada audiência de instrução, debates e julgamentos, realizada de maneira semi-presencial diante das diversas providências para redução da disseminação do novo Coronavírus Covid 19, conforme Provimento 2556/2020 de 07/05/2020.

Produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas arroladas. Ato contínuo, ocorreu a inquirição do acusado, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020. As partes ofertaram alegações finais.

O órgão ministerial rogou pela condenação do acusado, nos termos da exordial.

E a defesa postulou pela absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), imagens do entorpecente (fls. 46/48), relatório final (fls. 115/118), laudo toxicológico definitivo (fls. 156/168), bem como pela prova oral produzida em juízo.

I- DA PROVA ORAL.

A testemunha de acusação e policial militar Douglas Piauí da Silva (fls. 08) relatou que estava de patrulhamento no pátio do Posto Viajantes, Avenida Rio Grande do Sul, no momento em que viram um veículo VW Gol, em que reconheceram "Baiano" que praticava tráfico de drogas. Alegou que o acusado acelerou o veículo, causando suspeitas, pois, aparentava querer fugir dos policiais, e após um quilômetro e meio, foi cercado pelas viaturas, e tentou correr. Declarou que ao realizar a vistoria do veículo, encontrou um pedaço de maconha, debaixo do banco do motorista, além de uma faca média de corte, a quantia de R\$ 1.758,00, um aparelho celular, no qual não localizaram mais nada de ilícito. Narrou que deu voz de prisão ao réu Joaquim pelo crime de tráfico de drogas, sendo necessário o uso de algemas, visto que ele tentava resistir a prisão.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Willian Calister de Almeida (fls. 09).

No interrogatório, o acusado confirmou que momento antes da prisão adquiriu pelo valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) o entorpecente, abordado pela polícia a droga encontrada. Comentou que não possuía habilitação para direção de veículo automotor e que o estupefaciente duraria 2 (dois) meses.

## II- FATO TÍPICO:

A versão apresentada pelo denunciado apresenta-se desamparada de provas produzidas nos autos.

Isso porque as testemunhas arroladas por sua defesa não foram capazes de rechaçar os depoimentos prestados pelos policiais.

Em Juízo, os milicianos narraram os fatos com riqueza de detalhes, que o acusado foi abordado no momento que conduzia veículo automotor e na diligência da polícia, especialmente, a vistoria no automóvel, grande quantidade de entorpecente localizada.

Destaca-se que o fato das testemunhas arroladas pela acusação serem os policiais responsáveis pela prisão em flagrante não afasta a validade de seus depoimentos prestados em Juízo, uma vez que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa. Ainda, embora não avistado ou verificado indícios de comércio em momento pretérito a diligência policial, é certo que a QUANTIDADE desautoriza a conclusão de que a droga destinava-se EXCLUSIVAMENTE ao consumo pessoal.

O Acusado confirmou a posse/propriedade do entorpecente, porém, como dito, justificando que o destino visava ao consumo pessoal "no sítio".

Temos então a versão do acusado declarando-se usuário e que adquiriu razoável quantidade de entorpecente para 2 (dois) meses. E os policiais comentando sobre os antecedentes do acusado, especialmente, seu envolvimento com o tráfico.

Na oportunidade, ainda, encontrado importância em dinheiro na posse do Acusado.

Nesse cenário, especialmente, a QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, atrelado ao fato que o entorpecente localizado em ambiente particular (veículo) TRANSITANDO EM VIA PÚBLICA, ou seja, o Acusado NÃO se encontrava em sua residência, entendo inexistir dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito em questão, razão pela qual afasto a tese da defesa de absolvição por faltas de provas.

Consigne-se que as declarações dos policiais que participaram da ação foram unânimes no sentido de que a droga apreendida pertencia ao acusado. Observa-se, ainda, que as narrativas deles, em linhas gerais, não apresentam distorção de conteúdo, sendo reproduzidos em juízo e confirmados os dizeres inquisitoriais.

Deste modo, ao sentir desse julgador, deve ser valorizada a carga de veracidade que merece o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão do denunciado, diante do fato da apreensão e da ausência de prova acerca do interesse na incriminação gratuita.

Assim, tem-se que os depoimentos das testemunhas e a quantidade de entorpecente - 408,72g (quatrocentos e oito dez gramas e setecentos e vinte miligramas) - constituem elementos aptos a demonstrar que a conduta do denunciado se amolda perfeitamente àquela descrita na denúncia, qual seja o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, notadamente quanto ao núcleo verbal "transportar".

No mais, não se faz necessária a demonstração do fim de mercancia para a configuração do delito.

Portanto, caracterizado a prática criminosa acomodada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 praticada pelo denunciado.

## III - Da dosimetria da pena

Diante das provas colhidas nos autos, está claramente demonstrado que o acusado realizou conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal indicado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ante a sua culpabilidade, necessária condenação cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena base mínima de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

No mais, observo que o tipo penal em questão, busca proteger a sociedade, visando à erradicação de substâncias nocivas para a saúde pública, como é o caso dos entorpecentes, instrumento eficaz, infelizmente, para a corrosão da família

brasileira.

Destarte, certa a materialidade e autoria, passo a dosar a medida a ser imposta. O acusado não ostenta histórico criminal relevante (as condenações com trânsito em julgado posterior ao prazo de 5 anos) tornando-se favorável a apuração da personalidade do agente, circunstância prevista no artigo 59 do Código Penal e preponderante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A reincidência (pelo cometimento do crime de PORTE DE ENTORPECENTES) do acusado será apreciada nas fases seguintes. Igualmente, não há elementos desabonadores da conduta social. O motivo do crime foi inerente ao tipo, qual seja o lucro fácil. A natureza da droga apreendida, sendo certo que a maconha, comprovadamente, tem efeitos deletérios graves sobre a saúde humana, logo, circunstância do crime que deve ser considerada. As consequências e o comportamento da sociedade não são dignas de relevo. Destarte, nestas condições, o número de circunstâncias judiciais (08 – art. 59, CP), em número favorável ao acusado, é motivo suficiente para a fixação da reprimenda básica ao delito, pelo qual FIXO a pena base para o delito de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, o acusado faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, confissão espontânea, já que a sua conduta processual contribuiu para o juízo de certeza, e as suas declarações foram utilizadas para fundamentar a condenação, embora NÃO tenha reconhecido o dolo de comércio ilícito. Insta observar que “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude” (RT 683/281).

Possível a aplicação da reincidência, entretanto, as Turmas da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, têm decidido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (HC n. 535.785/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2019). Logo, com base neste entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicar a reincidência pela condenação anterior pelo crime de PORTE DE ENTORPECENTE (desclassificação no recurso do tráfico para o porte de entorpecente).

Todavia, considerando apenas a confissão, e que a pena base foi fixada no mínimo legal, respeitando-se, assim, na fase da dosimetria da pena provisória, os limites da cominação, na trilha do enunciado da Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas a 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminal”), já que desatendido o requisito, pois, pela quantidade, é possível a conclusão de que o denunciado, sem profissão ou relação de emprego formalizada, conforme ausência de comprovação, não atua de forma individual, e especialmente, ocasional, movimentando a mercancia ilícita como meio de vida, não se acomodando no de traficante de primeira viagem. Aliás, a utilização da quantidade de drogas apenas em uma das fase da dosimetria da pena encontra respaldo na jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal (HC nº 112.776): “O princípio do ne bis in idem ou non bis in idem, como se sabe, traduz a proibição de sancionar ou punir alguém duas ou mais vezes pelo mesmo fato.

Constitui, por isso, inequívoco limite ao poder punitivo do Estado consagrado no âmbito da legislação penal internacional (cf. PRADO. Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 158). A propósito, a Convenção Americana dos Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, ratificado no Brasil pelo Decreto 678, de 1992, acolheu o princípio do non bis in idem em contexto específico, ao estabelecer que “o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos” (art. 8º, 4). A partir de uma compreensão ampliada desse princípio, não restrito à impossibilidade das persecuções penais múltiplas, desenvolveu-se uma das suas mais relevantes funções no direito penal

constitucional: balizar a individualização da pena, com vistas a impedir mais de uma punição individual pelo mesmo fato em momentos diversos do sistema trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68). Daí o fundamento pelo qual não se admite, por exemplo, o reconhecimento da agravante "contra mulher grávida" (art. 61, II, "h", do CP) para aumentar a reprimenda do crime de aborto, ou que o homicídio qualificado pelo motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I) sofra a incidência da agravante genérica do art. 61, II, "a", do Código Penal ("por motivo fútil ou torpe"). Ainda nesse sentido, a jurisprudência desta Corte - na linha, aliás, da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, circunstância judicial") -, reconhece ilegítimo bis in idem (ou dupla valoração) "quando os fatos considerados maus antecedentes embasem também o agravamento da pena pela reincidência" (HC 96046, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 02-05-2012). No mesmo sentido: (HC 99044, Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 21-05-2010; HC 107556, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 01-07-2011; HC 99044, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 21-05-2010; HC 80066, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 06-10-2000). Ainda recentemente, no julgamento dos AP 470 EDj-décimos terceiros, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 10-10-2013, ficou assentado que "há bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime".

Assim, torno definitiva a pena base à míngua de circunstâncias modificadoras. FIXO o regime inicial fechado conforme a redação do artigo 33, § 3º, do Estatuto Repressivo Brasileiro, pois, ainda que se trate de acusado tecnicamente primário, e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2º, b), mostra-se necessária a consideração que o legislador constituinte evidenciou, expressamente, a gravidade da conduta (art. 5, XLIII, da CF) de tráfico de drogas, especialmente, na hipótese vertente, em que transportado grande quantidade de droga (408,72g). É bom lembrar que, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, com redação dada pela Lei nº 11.464/2007, pelo Plenário do STF - HC nº 111.840/ES -, o regime fechado não é mais obrigatório para os crimes hediondos ou equiparados.

Diante disso, o regime carcerário a ser fixado deve levar em consideração o regramento previsto no artigo 33 do Código Penal. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, o regime de tratamento mais severo previsto na Constituição Federal, e a quantidade e variedade de droga localizada em poder da acusado, e a não utilização da causa de diminuição acima mencionada, o regime só pode ser o fechado. Aliás, observo o tempo de prisão cautelar (23/08/2021 - prisão em flagrante, até a data do julgamento - 29/06/2022), totalizando, aproximadamente, 10 (dez) meses, bem como, a redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei nº 12.736/2012 ("O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade"), não altera o panorama, já que a previsão para o requisito objetivo para 2/5 (dois quintos) da pena é para 23/08/2023, concluindo pela manutenção do regime fechado.

Importante assinalar o texto do enunciado da Súmula nº 718 do E. Supremo Tribunal Federal, o qual sigo como orientação doutrinária - "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada".

Convém alicerçar que o E. Supremo Tribunal Federal (HC nº 97.256/RS) apontou a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no tráfico ilícito de drogas. Aliás, em 15.02.2012, o Senado editou a Resolução nº 05/2012, dispondo no artigo 1º: "É suspensa a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS".

Logo, passo a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva

de direitos, o legislador estabeleceu, no artigo 44 do Código Penal, critérios para orientar a avaliação sobre a necessidade e suficiência da benesse. No caso dos autos, o acusado não satisfaz os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, especificamente, que a pena do crime doloso é superior a 4 (quatro) anos.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006) e deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR JOAQUIM CARLOS FERNANDES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

MANTENHO a prisão cautelar do acusado nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal ("O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"), conforme alteração promovida pela Lei nº 12.736/2012, pois, o réu se encontra preso em razão do presente processo e assim deverá permanecer até o trânsito em julgado desta decisão, eis que persistem os motivos que ensejaram a segregação provisória, os quais são reforçados pela confirmação da condenação. Resumindo, RATIFICO a decisão que determinou a segregação durante o trâmite do processo, recomendando-se.

CONCEDO ao acusado a gratuidade judiciária. ANOTE-SE.

Custas ex legis.

No tocante ao NUMERÁRIO apreendido como NÃO HÁ PROVA DE COMÉRCIO DE DROGAS ANTERIOR A APREENSÃO do entorpecente, levantada a dúvida da origem na exordial a acusatória, a prova testemunhal apontou pela alienação de gado, fato não afastado pelo conjunto probatório, de modo que, com o trânsito em julgado, autorizada a restituição da quantia ao Acusado, expedindo-se a respectiva guia de levantamento em seu favor.

DETERMINO a suspensão dos direitos políticos do réu, conforme o artigo 15, III, da Constituição Federal, oficiando-se ao T.R.E. competente; (3) CUMPRA-SE o disposto nos artigos 479 e 482 das NGSCGJ, com sua redação determinada pelo Provimento-CG nº 11/2015, de modo a intimar o réu para o pagamento da pena de multa e das custas judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de comunicação à Procuradoria Geral do Estado; (4) LANCE o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Andradina, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA